

BAB II

KAJIAN PERMASALAHAN

A. Perwalian Dalam Hukum Perdata Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian

A. Pengertian perwalian

Sebelum membahas mengenai pengertian perwalian dalam Islam terlebih dahulu perlu untuk diketahui perbedaan antara wali dengan perwalian. Wali berasal dari bahasa Arab yakni berasal dari kata ” () yang artinya amat dekat”⁸. Jadi yang dimaksud dengan wali adalah seorang atau sekelompok orang yang paling dekat dan yang berhak mengurus juga yang berhak menjaga harta atas orang yang dibawah perwaliannya baik itu dari sejak waktu ia ditetapkan keadaannya menjadi wali, maupun ditetapkan oleh putusan hakim. Sedangkan wali dalam istilah fiqih adalah orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain yang sesuai dengan bidang hukumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan perwalian adalah suatu permasalahan tentang wali yakni kepada siapa akan dijatuhkan hak kewalian seseorang atau barang apabila wali yang telah ditetapkan tersebut sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia sehingga kepada siapa yang harus ditunjuk sebagai wali atas orang atau barang yang tidak mempunyai wali.

8. A Sya’bi, Kamus An Nur, Arab Indonesia, Halim, Surabaya, 1997, Hal : 299

Istilah perwalian dalam fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan atau dengan kata lain perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Maka dengan demikian perwalian itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : perwalian atas keperibadian seseorang dan hartanya, perwalian atas barang dan perwalian atas perempuan yang hendak mau kawin.

a. Perwalian atas seseorang dan harta bendanya.

Perwalian atas orang termasuk dalam istilah perwalian yang secara umum. Dikatakan umum karena perwalian ini berkenaan antara manusia dengan manusia. maksudnya yakni perwalian atas orang-orang yang belum cakap dalam bertindak hukum. guna menjaga harta dan jiwanya Seperti perwalian atas orang gila, orang safih atau idiot, dan anak dibawah umur.

b. Perwalian atas orang perempuan yang kawin.

Perwalian ini termasuk dalam kategori perwalian umum. dikatakan umum karena perwalian ini berkenaan antara manusia dengan manusia. Yakni perwalian yang membahas dalam hal seorang gadis perempuan yang hendak akan menikah namun karena ada kekurangan terhadap dirinya maka perlulah adanya wali yang akan menikahnya. Oleh sebab itu perwalian dalam pernikahan ini adalah merupakan rukun nikah dalam hukum perdata islam.

Masalah perwalian juga sangat berkaitan erat hubungannya dalam masalah wala' () yakni ketuanan, istilah wala' yang berkaitan dengan hak waris mewarisi yang diberikan kepada seseorang yang memerdekakan hamba sahayanya *budak* atau seseorang yang mendapat

warisan karena ada sumpah setia antara dua orang untuk saling membantu dalam berbagai kesulitan yang dihadapi dan saling mewarisi. perwalian dalam bentuk pertama adalah hak perwalin dan ahli waris yang ada pada tuan terhadap hamba sahayanya yang telah dimerdekakan. oleh seorang tuan berhak menjadi ahli waris muthlak *ashobah* dari semua peninggalan hamba sahayanya, bila hamba sahayanya itu tidak memiliki ahli waris lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya :

“ bahwa perwalian itu hanya hak bagi orang yang memerdekakan “ (HR Al Bukhari dan Muslim)⁹

Sedangkan bentuk perwalian yang kedua adalah *wala' almu'awallah* yakni perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan yang mereka hadapi : termasuk mereka sama sama untuk bertanggung jawab untuk membayar sanksi *diat* apabila salah satu diantara mereka yang melakukan tindak pidana yang mewajibkan diat. Tapi perwalian ini disyaratkan bagi orang yang mengangkat wali tidak mempunyai wali *nasab* atau keturunan. Dan juga disyaratkan dalam mengambil wali harus yang dewasa dan sudah cakap dalam bertindak hukum.

Sedangkan menurut para pakar hukum Islam, mendefinisikan perwalian sebagai berikut.

Menurut Drs. Dedi Junaedi “Pembicaraan masalah perwalian dalam islam terbagi kepada dua kategori, perwalian umum dan khusus. Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti

9. Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2001, cet 5, Hal: 1945

waliyul amri (dalam arti gubernur) dan sebagainya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.”¹⁰

Sedangkan menurut Muhammad jawad Mughniyah. Mendefinisikan perwalian sebagai berikut.” Perwalian adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar’I* atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.”¹¹ dan pendapat ini adalah merupakan kesepakatan diantara beberapa para ulama’ mazhab yang berkembang selama ini. Selain definisi definisi yang dikemukakan oleh para pakar hukum islam diatas tadi, masih banyak juga definisi atau pendapat dari pakar hukum lainnya, namun pendapat pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah dipaparkan diatas.cuma perbedaannya terdapat pada kalimatnya sedangkan pada maknanya sama.

B. Dasar Dasar Hukum Perwalian dalam Hukum Perdata Islam.

Pada dasarnya, dasar hukum perwalian itu terbagi menjadi dua bagian yaitu dasar hukum perwalian terhadap orang orang yang belum cakap dalam bertindak hukum. dan dasar hukum perwalian dalam hal perkawinan.

Sebagai dasar hukum perwalian dalam hal perkawinan adalah sebagaimana firman Allah dalam Alqur’an yang berbunyi :

10. Dedi junaedi, Bimbingan Perkawinan , Akademika Pressindo, Jakarta 2001, Cet pertama hal:104.

11..Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh lima Mazhab ,penerbit Lentera,,Jakarta 2000, Cet Lima.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan (Qs An Nur: 32)¹²

Dalam hadis Rasulullah juga telah disebutkan bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak ada wali, hadis tersebut berbunyi :

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, jika ia sempat menggauli wanita itu maka ia telah berhak mendapatkan maskawin dengan apa yang menghalalkan kelaminnya itu. Kemudian bila (para walinya) itu menolak mengawinkan maka sultan (hakim) adalah wali bagi siapa wanita yang tidak mempunyai wali. (HR Imam yang empat kecuali Nasa’i.)”¹³

Sedangkan yang menjadi dasar hukum atas kedua perwalian tersebut yakni perwalian terhadap anak dibawah umur dan perwalian dalam perkawinan. adalah sebagaimana yang telah tertera dalam Hukum perdata Islam yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 107 ayat 1 – 4 yang berbunyi.

12. M Sa'id, Tarjamah Alqur'an Alkarim, Al Ma'rif, Bandung 1987, Cet 1, Hal: 316

13 Menurut Imam Tirmizi, hadis ini hasan, dan Al Qurtubiy menyatakan bahwa hadis ini shahih, dan menurut Imam Hakim, riwayat tentang hal ini memang benar datang dari istri-istri

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum

Dari beberapa dasar hukum perwalian diatas tadi adalah merupakan dasar hukum perwalian dalam hukum perdata Islam sedangkan dasar hukum menurut hukum perdata sipil akan dibahas pada pasal yang berikutnya nanti.

2. kedudukan hukum , sebab dan tujuan perwalian

A. Kedudukan hukum perwalian

Wali adalah kekerabatan yang diakui keberadaanya menurut hukum islam yang membawa hak dan kewajiban bagi seorang wali. Ia berhak sebagai wali dan berhak menjaga serta mengelola atas harta orang yang ada di bawah perwaliannya baik perwaliannya karena ditunjuk oleh seseorang yang baru menganut agama islam. Sedangkan wali yang berdasarkan atas Seorang budak yang dimerdekakan, seorang tuan berhak menjadi wali dan sekaligus berhak

Rasullullah SAW. Diantaranya Siti Aisyah Umu salamah, Zainab, dan menurut Ibnu Munzir tak diketahui seorang sahabatpun yang menyelisihnya.

mendapatkan harta pusaka atau warisan dari hamba sahayanya yang telah ia merdekakan apabila budak tersebut tidak mempunyai ahli waris lainnya.

Wali yang memerdekakan dapat dikategorikan sebagai *ashobah sababiyyah* yakni suatu hak mewarisi keseluruhan harta peninggalan seorang budak yang dimerdekakan disebabkan ia telah memerdekakan hamba sahaya. Ia berhak menjadi ahli waris tunggal dari harta peninggalan harta budaknya bila tidak ada ahliwaris *nasabbiyah* (keturunan yang menjadi ahli warisnya) haknya sebagai ahli waris tunggal hanya berperan sebagai ahli waris *binnafsih*. Ahli waris yang menghabisi semua harta peninggalan setelah dibagikan kepada *zawil furud* (orang yang telah ditentukan jumlah bagiannya dalam hukum islam) seperti anak kandung.

Sebagaimana Hadis nabi yang Artinya;

“Hubungan tuan yang memerdekakan (wali) dengan hamba sahayanya yang dimerdekakan adalah merupakan sebagian dari darah dagingnya, sama halnya dengan darah daging senasab / keturunan “ (HR Ibnu Hibban dan hakim) oleh karenanya tuan yang memerdekakan berhak menjadi ahliwaris terhadap budak yang di merdekakannya

B. Sebab sebab terjadinya perwalian.

1. Dengan sebab adanya hubungan darah

Adapun sebab sebab terjadinya perwalian adalah dengan sebab nasab atau adanya hubungan darah dengan orang yang ada dibawah perwaliannya seperti sorang anak yang mempunyai wali atas orang tuanya. Atau orang yang paling dekat hubungan darahnya apabila wali ayah sudah tidak ada.

2. Dengan sebab wasiat.

Sebab terjadinya hubungan perwalian dengan sebab wasiat adalah pengangkatan wali atas kehendak orang tua seorang anak kepada orang lain dengan alasan tertentu seperti, tidak ada yang dapat menggantikan dirinya sebagai wali dari keluarga yang terdekat, merasa kurang percaya terhadap keluarga terdekatnya itu untuk dijadikan sebagai wali terhadap anaknya, dan lebih mempercayakan orang lain sebagai wali dari anaknya karena dengan alasan lebih cakap dan pandai dalam bertindak hukum.

3. Dengan sebab hak mewarisi

Selain itu juga, penyebab terjadinya perwalian bisa disebabkan karena adanya hubungan hak mewarisi yang diberikan kepada seseorang yang memerdekakan seorang hamba sahayanya (budak).¹⁴ Seorang tuan berhak menjadi ahli waris mutlak *asobah* dari semua peninggalan hamba sahayanya, bila hamba sahayanya tersebut tidak memiliki ahli waris yang lain. Menyangkut masalah ini ulama' fiqih sepakat berpendapat bahwa seseorang yang memerdekakan hamba sahayanya atas kemauannya sendiri berhak menjadi walinya. Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi yang berbunyi :

“ bahwa perwalian itu hanya hak bagi orang yang memerdekakan “ (HR Al Bukhari dan Muslim).

3. Dengan sebab *wala' al mu'awallah*

Wala' al mu'awallah maksudnya adalah perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai

14. Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ikhtiar Baru Van hoeve, Jakarta 2001, Cet 5, Hal: 1917.

kesulitan yang mereka hadapi : termasuk mereka sama sama bertanggung jawab untuk membayar sanksi *diat* bila salah satunya melakukan tindak pidana yang mewajibkan *diat*”¹⁵. Disyaratkan bagi orang orang yang mengangkat wali yang tidak mempunyai wali *nasab* keturunan. Dan ia sangat membutuhkan wali dalam kehidupannya. Di sisi lain wali yang ditunjukannya tersebut adalah orang orang sudah dewasa dan waras akalnya serta cakap dalam bertindak hukum.

B. Tujuan adanya perwalian

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap tindakan hukum itu mempunyai tujuan yang sangat bermanfaat bagi setiap insan apalagi menyangkut keselamatan jiwa dan harta seseorang dari orang orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu masalah perwalian ini mempunyai tujuan yang baik yakni tujuan yang bernilai ibadah dan merupakan bagian dari ajaran agama islam adapun tujuan daripada perwalian ini terbagi menjadi dua yakni tujuan perwalian dalam hal perkawinan dan juga tujuan perwalian dalam anak dibawah umur. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1 Adapun tujuan perwalian dalam hal perkawinan adalah

- Untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan karena wali dalam pernikahan itu adalah sebagai bagian dari rukun nikah dalam islam.
- Wali bertujuan untuk menikahkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya

15. Ibid Hal : 1915

- Adapun keberadaan wali itu sebagai tempat kembali seorang perempuan yang apabila akan terjadi perceraian dengan suaminya, maka perempuan tersebut harus kembali kepada walinya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kemelaratan hidup perempuan tersebut.

2. Adapun tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah.

- Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.
- Wali bertindak sebagai pengaman, dalam artian bahwa wali itu selalu menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah perwaliannya itu.
- Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia.maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya akan terselamatkan.
- Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang orang yang mengadakan *wala' al mu'awallah* perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.
- Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin.dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk

keperluan hidupnya sehari-hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu. sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

“ Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut. (An Nisa :6)¹⁶

Hal ini juga dapat diperkuat dengan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 112 yang mengatakan.

“ Wali dapat mempergunakan harta yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut keputusan atau billma'ruf kalau wali itu fakir. “

3. Syarat dan rukun perwalian dalam Hukum Perdata Islam

1. Syarat-syarat Perwalian

a. dalam hal anak dibawah umur

Para ulama' mazhab menyepakati bahwa, wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama dengan orang yang dibawah perwaliannya itu. bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus *adil* sekalipun wali itu diangkat dari ayah dan kakek.¹⁷

16. H Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar baru Algesindo, 2001, Cet 34, Hal: 1317.

17. M Jawad Mughniah, Fiqh Lima Mazhab, Lentera, 2000, Cet 5, Hal : 696.

Selain itu juga sebagai syarat bagi seorang wali didalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang wali dalam harta yang berada dibawah perwaliannya itu, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat. Maka perwaliannya itu dianggap sah, sedangkan yang menimbulkan mudharat maka perwaliannya itu tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak mudharat. Sebagian ulama' imamiyah membenarkan manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakeknya sebab yang disyaratkan disitu adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa maslahat bagi dirinya.

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada tindakan tindakan yang membawa manfaat saja dan sangat dilarang dalam tindakan tindakan yang tidak bermanfaat karena hal tersebut dapat merugikan orang yang ada dibawah perwaliannya.

Dari persyaratan persyaratan dikemukakan tadi adalah merupakan sebagian besar dari persyaratan seorang untuk menjadi wali dalam hal perwalian terhadap anak dibawah umur.

b Syarat perwalian dalam hal perkawinan

Persyaratan seseorang yang dapat dijadikan sebagai wali dalam perkawinan menurut islam, tidak semua orang bisa dan dapat dijadikan wali, karena wali tersebut akan bertanggung jawab terhadap sah dan tidaknya

pernikahan seseorang. Oleh sebab itu islam mensyaratkan wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang memiliki sifat sebagai berikut.

1. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak dapat dijadikan wali, juga tidak sah kewaliannya. Sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an yang berbunyi :

” Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu.” (Al Ma'idah : 51)

2. Baligh. Yang dimaksud dengan baligh adalah (sudah berumur 15 tahun) dan sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Sebagaimana syarat ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 107 ayat 4 yang berbunyi

“ Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum “

3. Berakal yakni orang waras dan bukan orang gila atau safih (idiot)
4. Merdeka. Orang sebagai wali haruslah orang yang merdeka yakni orang yang tidak berada dalam kekuasaan seorang tuan sebagaimana kebiasaan orang terdahulu.
5. Laki laki karena telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Daruqutni. Yang berbunyi :

“ Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.

(HR Ibnu Majjah dan Daruqutni)

6. Adil.yang dimaksud dengan adil disini adalah dimana seorang yang diangkat sebagai wali harus dapat bersikap adil baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya.

2. Rukun perwalian dalam islam

Istilah kata rukun berasal dari bahasa Arab yakni yang artinya tiang, dasar, seperti dalam rukun islam yakni (sebagai dasar penetapan hukum islam) dan seperti dalam rukun iman (sebagai dasar dalam keimanan kita) adapun rukun yang dimaksud dalam perwalian ini adalah : sesuatu yang sangat mendasar sekali yang dapat mengakibatkan terjalinnya hubungan perwalian terhadap seseorang. Adapun rukun rukun yang dimaksud adalah Sbb

1. Wali yakni seseorang yang sudah siap mau untuk dijadikan wali terhadap orang yang membutuhkan perwalian.
2. Harta benda dan anak atau orang yang tidak mempunyai wali yang dapat mengatur dan menjaganya sehingga seseorang yang membutuhkan perwalian dengan sebab ada kekurangan terhadap dirinya, oleh sebab itu sangat memerlukan wali.yang dapat menjaga jiwa dan hartanya.

3. Bukti dan saksi. yang apabila seseorang akan berwasiat kepada orang lain untuk memindahkan hak kewaliannya maka harus ada saksi dan bukti yang kuat tentang dirinya yang akan dijadikan sebagai wali

d. Urutan dalam perwalian

1. Urutan perwalian dalam pernikahan

Adapun urutan wali dalam perkawinan ini banyak sekali perbedaan konsep dan pandangan para ulama' fiqih tentang urutan wali dalam pernikahan. Menurut garis besarnya urutan wali nasab yang sering digunakan dan ditemukan di dalam buku-buku fiqih masalah pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Ayah (bapak)
2. Kakek
3. Saudara kandung
4. Saudara sebapak
5. Anak saudara sekandung
6. anak saudara sebapak
7. Saudara ayah sekandung (paman)
8. Saudara ayah sebapak (paman)
9. Anak saudara ayah sekandung (sepupu)
10. Anak saudara ayah sebapak (sepupu)

Apabila wali nasab diatas tadi tidak terdapat pada wali yang perempuan maka dengan demikian mempelai perempuan tersebut tidak boleh

menikahkan dirinya, sebagaimana disebut di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya

Seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita dan tidak pula mengawinkan dirinya (HR Daruqutni)

Maka dengan demikian keadaan seperti ini maka muncullah pengganti walinya yakni dengan istilah wali hakim. Sedangkan yang dimaksud wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri agama)¹⁸ untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai wali nashab sama sekali.
2. Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaanya)
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
4. Wali yang berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qashri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92, 5 km.
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
6. wali *adhol* artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anaknya.
7. Wali yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah

Dengan demikian apabila kondisinya salah satu dari tujuh point diatas tadi, maka yang berhak menjadi wali dalam hal ini adalah wali

hakim.akan tetapi dikecualikan bila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak selaku wali.maka orang yang diwakilkan itu berhak menjadi wali.

Adapun diantara dalil yang berkaitan dengan wali hakim adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi.

“ Kemudian bila (para walinya)itu menolak mengawinkan (adhol) maka hakim (pengusaa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya. (HR.Ahmad dan Abu Daud)¹⁹

Apabila wali hakim tidak ada maka perwaliannya berpindah pada wali *Muhakam* adapun yang dimaksud dengan wali muhakam adalah “orang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.”¹ Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim diatas kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad perkawinan diwilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.

18.Dalam peraturan Menteri Agama (PMA) No 2 Tahun 1987, Orang yang menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

19. Drs Dedi Junaidi Bimbingan perkawinan Akademika presindo jakarta 2001 hal113

20. Ibid.

Adapun urutan wali diatas tadi merupakan urutan wali yang biasa kita di terapkan oleh agama islam di Indonesia. Namun perlu juga kita ketahui bahwa dalam perwalian pernikahan ini banyak sekali para ulama berbeda pendapat mengenai urutan wali tersebut terutama dari kalangan ulama' dari beberapa Mazhab.

Dan berikut pendapat para ulama' mengenai urutan wali dalam hal pernikahan.

1. Abu hanifah

Pendapat Abu Hanifah atau yang dikenal dengan mazhab hanafi beliau berpendapat bahwa urutan pertama wali itu ada ditangan anak laki laki wanita yang akan menikah itu, jika ia memang punya anak, meskipun anak hasil zina. Kemudian berturut turut: cucu laki laki (dari pihak anak laki laki), ayah, saudara kandung, saudara laki laki seayah, anak saudara laki laki sekandung, anak saudara laki laki seayah, paman, (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.²¹

2. Imam Maliki

Imam maliki berpendapat bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut turut: saudara laki laki, anak laki laki, dari

21. M Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab Lentera 2000, Cet 5, Hal: 693.

saudara laki laki, kakek, paman, (saudara ayah) dan seterusnya dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.²²

3. Imam As Syafi'I

Urutan pertama yang digunakan imam syafi'I adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki laki sekandung , saudara laki laki seayah, anak laki laki,dari saudara laki laki, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada maka perwalian beralih ke tangan hakim.²³

4. Imam Hambali

Imam hambali memberikan urutan pada urutan pertamanya adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.²⁴

2. Pendapat para Imamiyah

Sebelum penulis menuliskan pendapatnya imamiyah terlebih dahulu perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan imamiyah. Adapun yang dimaksud dengan pendapat imamiyah adalah dinisbatkan kepada orang yang mempercayai wajib adanya imam serta percaya pada ketetapan nash (teks) dari Rasulullah bahwa imam Ali bin abi thalib, sebagai khalfah.Fiqih Imamiyah dinamakan fiqih Ja'fari.²⁵ Adapun pendapat imamiyah mengenai perwalian imamiyah mengatakan bahwa perwalian itu hanya ditangan ayah

22. Ibid , Hal : 694

23. Ibid. Hal: 347.

24. Ibid

25. Ibid Hal: xxiii (Pendahuluan).

dan kakek dari pihak ayah, serta dalam kasus kasus tertentu hakim, baik ayah maupun kakek dari pihak ayah, mempunyai

hak penuh dalam perwalian terhadap akad nikah bagi anak laki laki dan perempuan kecil.juga terhadap orang yang sudah baligh tapi gila atau idiot *safih*.bila itu gila atau idiot dari sejak kecil. Akan tetapi bila ketika mereka itu

berakal sehat, lalu gila atau menjadi idiot, maka ayah dan kakek tidak punya hak perwalian atas kedua jenis orang tersebut, tapi perwaliannya dipindahkan kepada hakim, sekalipun ayah dan kakeknya masih ada. Kalau sang ayah memilih seseorang (sebagai wali mereka), sedangkan kakeknya memilih orang lain, maka yang didahulukan adalah pilihan kakeknya.

Para ulama' imamah mensyaratkan, bahwa perwalian itu, baik untuk ayah, kakek atau hakim baru dapat dilaksanakan jika tidak merugikan sang anak. Maka, kalau si anak kecil merasa dirugikan oleh pernikahan tersebut, maka dia boleh memilih ketika baligh.apakah menggugurkan akadnya atau melanjutkan.²⁶

Selanjutnya dalam hal ini juga Imam hanafi mengatakan bahwa, manakala ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak *sekufu'* (sepadan) atau kurang dari mahar *mitsil* , maka akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek. Akan tetapi bila yang mengawinkannya bukan ayah atau kakeknya, dengan

26. Ibid ,Hal 348.

orang lain yang tidak sepadan atau kurang dari mahar mitsil maka akad nkah tersebut tidak sah sama sekali.²⁷

Hambali dan maliki berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil kurang dari mahar mitsil. Sedangkan Imam Asyafii berpendapat bahwa tidak berhak atas itu, dan bila ia melakukannya juga, maka si anak boleh menuntut mahar mitsil bagi dirinya.

Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa bila seorang ayah mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil kurang dari mahar mitsil, atau mengawinkan anak laki lakinya yang masih kecil dengan mahar yang lebih dari itu, maka bila hal dipandang maslahat, akad dan maharnya sah, tetapi bila tidak mengandung maslahat, maka akadnya sah, namun keabsahan mahar tergantung pada izinnya. Apabila ia menyetujui mahar tersebut setelah ia baligh maka maharnya tetap seperti sedia kala.²⁸

Sedangkan mengenai wali hakim yang adil, seluruh mazhab sepakat bahwa wali hakim tersebut berhak mengawinkan laki laki dan perempuan gila, manakala mereka tidak mempunyai wali yang dekat.

2. Urutan Urutan wali dalam perwalian anak dibawah umur.

Adapun urutan urutan wali dalam hal perwalian terhadap anak dibawah umur, para ulama' menyepakati bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut sebagian ulama' syafi'i.²⁹ Selanjutnya para mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah. Berikut pendapatnya.

27. Ibid

28. Ibid.

1. Hambali dan maliki

Kedua imam ini mengatakan bahwa wali sesudah ayah, adalah orang yang menerima wasiat dari ayah . kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ketangan hakim syar'i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak mempunyai hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa menempati posisi ayah, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu.maka apalagi kekek dari pihak ibu.³⁰

2. Imam hanafi

Beliau mengatakan para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya. Dan kalau tidak ada maka perwaliannya jatuh ketangan *qadhi*.³¹

3. Imam Asyafi'I

Imam Asyafi'I berpendapat bahwa perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah.seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada *qadhi*.³²

Maka dengan demikian dari pendapat pendapat para ulama' diatas tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan ulama' berpendapat bahwa wali

29. Ibid Hal : 693

30. Ibid.

31. Ibid

32. Ibid Hal : 394

yang diutamakan adalah ayah, kakek, dan kemudian kepada orang yang di berikan wasiat akan tetapi orang yang diberikan wasiat tersebut diutamakan dari keluarga, yakni wali yang mempunyai hubungan darah yang paling dekat. Sedangkan wali dari pihak ibu para ulama' sepakat tidak ada.

Sedangkan didalam Hukum perdata Islam yakni yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Sbb :

Pasal 107 ayat 4, menyebutkan bahwa Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Sedangkan pada pasal 108 menyebutkan bahwa, orang tua dapat mewasiatkan kepada seorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam urutan urutan wali menurut para mazhab sangat berpariasi. Sedangkan dalam KHI tidak disebutkan urutannya, akan tetapi hanya ditekankan pada syarat untuk menjadi wali, namun hal ini sudah menjadi ketentuan hukum perdata islam di Indonesia.

e. Kewajiban bagi para wali.

Pada dasarnya kewajiban para wali terhadap orang yang ada dibawah perwaliannya sangat banyak sekali namun pada pasal ini penulis akan menulis hanya beberapa bagian saja. Adapun kewajiban para wali terhadap orang yang dibawah perwalinya terbagi menjadi dua, pertama kewajiban wali dalam pernikahan dan kewajiban wali dalam hal anak dibawah umur.

1. Kewajiban wali dalam hal pernikahan.

a. Sebagai wali nikah

Sebagai seorang wali dalam pernikahan, wajib hukumnya untuk menikahkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya, karena mengingat fungsi wali adalah orang yang berhak menikahkan anaknya. sebagaimana hadist rasulullah SAW yang berbunyi :

“ Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh ayahnya” (Riwayat Daruqutni).

Dengan demikian maka kewajiban sebagai seorang wali dalam hal ini adalah sebagai orang yang menikahkan anaknya, karena sah dan tidaknya pernikahan ada pada walinya. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi :

“ Barang siapadiantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya maka pernikahannya batal “ (HR Imam empat kecuali nasa’i)

b. Sebagai penanggung jawab dalam pernikahan.

Orang tua atau wali, disamping sebagai orang yang menikahkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya, juga sebagai penanggung jawab baik didunia dan di akherat atas sah dan tidaknya pernikahan tersebut. Disamping itu juga sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pernikahan dari sejak awal sampai dengan berakhirnya suatu acara pernikahan. Adapun kalau terjadi perceraian. Maka sang wali harus bersedia untuk menerima hidup bersama lagi dengan anaknya dalam satu rumah.

2. Kewajiban wali terhadap anak dibawah umur.

Adapun kewajiban para wali terhadap anak dibawah umur, pada garis besarnya dapat di bagi sebagai berikut :

a. Mengeluarkan Berbagai hak.

Wali wajib mengeluarkan dari harta si anak hak hak yang wajib dilakukan atasnya, seperti membayar hutang, membayar zakat, membayar ganti rugi atas tindak pidana dan zakat, sekalipun tidak ada permintaan untuk itu kepada wali. Sedangkan pemberian nafkah terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawab si anak tidak boleh dibayarkan oleh wali tanpa adanya permintaan.

b. Pemberian Nafkah.

Sebagai seorang wali wajib hukumnya untuk mengeluarkan nafkah (infak) bagi orang orang yang ada dibawah perwaliannya menurut apa yang patut (ma'ruf) dan tidak boleh bersikap kikir atau terlalu boros dalam mengeluarkan infak tersebut. Tetapi sdang sedan saja menurut kebiasaan dimasyarakatnya.

c. Bertanggung jawab atas harta orang yang di bawah perwaliannya.

Wali atau washi (orang yang diberi wasiat) adalah dipercaya, tidak bertanggung jawab atas harta kecuali bila terbukti sengaja merusak atau melalaikannya. Maka pabila si anak telah baligh, lalu menuduh bahwa walinya telah melakukan pelanggaran terhadap hartanya, maka si anak harus mengemukakan bukti, sedangkan wali harus bersumpah. karena dia adalah orang yang dipercaya.

f. Larangan bagi para wali

Adapun larangan bagi para wali secara umum adalah sebalik daripada kewajiban para wali tersebut. Namun ada sedikit tambahan mengenai pelarangan tersebut yakni.

Sebagai mana pendapat imam syafi'I dan beberapa ulama' lainnya mengatakan bahwa wali atau washi tidak boleh membeli harta anak kecil atau orang gila yang berada dibawah perwalian mereka untuk diri mereka sendiri, dan tidak pula boleh menjual hartanya sendiri kepada si anak. Dan pendapat ini dipertegas oleh Imam abu hanifah, beliau menyatakan hal itu dilarang sebab hal tersebut berarti telah memutuskan suatu untuk dirinya sendiri, dan hal itu tidak dibenarkan.

Adapun bagi wali atau washi boleh mewakilkan kepada orang lain apabila ia tidak bisa menangani hal hal yang tidak bisa ia lakukan. Namun apabila sebaliknya maka wali atau washi dilarang untuk mewakilkan kembali.

g. Berahirnya dan Putusnya Perwalian Dalam Islam.

Adapun bagi setiap wali yang diberikan tanggung jawab yang berat dan kemudian tidak lalai dengan tugas tugasnya sebagai wali terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya baik itu terhadap jiwa dan hartanya maka, wali yang demikian itu adalah wali yang bertanggung jawab.³³ Namun apabila sebaliknya wali tersebut tidak bertanggung jawab yakni sering berbuat atau bertindak yang dapat merugikan anak anak yang berada dibawah perwaliannya, misalnnnya wali tersebut berubah menjadi seorang wali yang pemabuk, penjudi, pemboros, dan melalaikan

33. Ibid, Hal : 698

tugasnya sebagai wali, Hakim berhak memecat orang tersebut dari hak kewaliannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Hukum Perdata Islam, pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : Pengadilan Agama dapat mencabut perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, gila, dan melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Sedangkan yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perwalian untuk selamanya dan tidak dapat di sambung lagi sebagai hak perwaliannya yakni apabila dari seseorang wali dengan orang yang berada dibawah perwaliannya itu adalah dengan meninggalnya dari salah satu pihak, yakni orang yang sebagai wali atau orang yang berada dibawah perwaliannya.